

1502677-50.2021.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... relacionados ao envolvimento ao tráfico de drogas (fls. 159/168).

Das 4.213 munições apreendidas, boa parte eram próprias para fuzis e não possuíam numeração de lotes.

Agindo desta maneira, os indiciados DANIEL SANTOS DE JESUS e JOSENILO FERREIRA, praticaram os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502677-50.2021.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502677-50.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265255/2021 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 20534895 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 4096/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2265255 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL SANTOS DE JESUS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

DANIEL SANTOS DE JESUS e JOSENILO FERREIRA foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, c.c. art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006, e art. 16, da Lei 10.826/03, na forma de concurso material, porque: (1) desde data incerta até o dia 28 de setembro de 2021, nesta cidade e comarca de Assis, associaram-se para praticar o crime de tráfico de drogas; (2) ademais, no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 10h50min, na Rodovia Raposo Tavares, KM 453, Vila Boa vista, neste município e Comarca de Assis, traziam com eles, guardavam e transportavam, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, entre Estados da Federação, 12 porções de cocaína (crack), pesando aproximadamente 12,26 kg (doze

quilogramas e duzentos e sessenta gramas), e mais 5 porções de cocaína, pesando aproximadamente 5,3 kg (cinco quilogramas e trezentos gramas), substância que causa dependência psíquica; (3) por fim, nas mesmas circunstâncias acima descritas, mantinham sob suas guardas e transportaram 4.213 munições de uso restrito, sendo 3.750 cartuchos de calibre 7.62, e 463 cartuchos de calibre .50, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Eis a narrativa dos fatos constantes da denúncia:

Segundo se apurou, policiais militares em patrulhamento de rotina abordaram o caminhão placa MHP2I95/EMBU DAS ARTES/SP, chassi 93ZS2SSH098805953, Marca/Modelo: IVECO/STRALIHD 740S42TZN, tipo: Caminhão trator, ano fabricação: 2009, cor: branco, de propriedade do denunciado JOSENILO FERREIRA; bem como o semi-reboque a ele acoplado (placa AFL8I68/PARANAGUA/PR, Marca/Modelo: reb/schiffer, tipo: semi-reboque, ano fabricação: 1985, cor: Preta, proprietário: ANDRE ANTONIO DOS SANTOS -, os qual eram conduzidos pelo próprio JOSENILO acompanhado de DANIEL. Após as buscas, os milicianos lograram êxito em localizar, escondidos em um fundo falso em formato de cofre, entre as logarinas do chassi do cavalo trator, 12 (doze) tabletes de cocaína (crack), 05 (cinco) tabletes de cocaína, além de 3.750 (três mil, setecentas e cinquenta) munições do calibre restrito 7.62, e 463 (quatrocentos e sessenta e três) munições do calibre restrito .50 (cf. laudo do veículo de fls. 148/155).

As munições apreendidas foram submetidas à perícia técnica e o laudo pericial de fls. 156/158 conclui que elas são eficazes para a produção de disparos.

A quantidade de droga apreendida, e as circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que os denunciados traziam com eles, guardavam e transportavam a droga para posterior fracionamento e entrega ao consumo de terceiros, sendo que há mensagens no aparelho celular de DANIEL relacionados ao envolvimento ao tráfico de drogas (fls. 159/168).

Das 4.213 munições apreendidas, boa parte eram próprias para fuzis e não possuíam numeração de lotes.

Agindo desta maneira, os indiciados DANIEL SANTOS DE JESUS e JOSENILO FERREIRA, praticaram os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Notificados (fl. 196 e 198), os réus apresentaram defesa prévia (fls. 221/224) por meio de defensor constituído (fl. 98/99), a qual foi rejeitada, seguindo-se com o recebimento da denúncia (fls. 226/227).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus (fl. 466). As partes se manifestaram em alegações finais (fls. 494/500 e 502/517).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para: a) condenar o réu JOSENILO FERREIRA ao cumprimento de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao art. 16, da Lei 10.826/03; b) absolver os réus JOSENILO FERREIRA e DANIEL SANTOS DE JESUS das imputações referentes aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, respectivamente, do CPP. (fls. 521/528); c) absolver o réu DANIEL SANTOS DE JESUS da imputação referente ao crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/03, com base no art. 386, inc. V, do CPP (fls. 521/528 e 556).

O Ministério Público e a Defesa interpuuseram recursos. O Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, julgou prejudicado o recurso do Representante do Ministério Público, acolheu a preliminar ventilada pela r. Defesa do Apelante/apelado Josenilo Ferreira e declarou a nulidade da sentença, determinando a prolação de outra, analisando todos os tópicos questionados pela r. Defesa (fls. 636/641).

As partes se manifestaram e reiteraram o teor das alegações finais (fls. 657 e 660).

É o relatório.

II – Fundamentação

A princípio, com o fito de sanar a omissão reconhecida pelo E. TJ/SP, que provocou

a nulidade da sentença anteriormente proferida (fls. 521/528), passa-se à análise da preliminar de nulidade da busca policial, arguida pela Defesa do corréu JOSENILO.

Com efeito, sustenta a D. Defesa, em suma, que o nervosismo dos corréus, por si, não caracteriza justa causa, a autorizar a medida invasiva, de modo que a prova assim originalmente obtida encontra-se eivada de nulidade e, portanto, inaptas para alicerçar a sentença condenatória. Consequentemente, a solução adequada ao caso seria a absolvição dos acusados.

Tais argumentos, todavia, não merecem acolhimento.

Consoante preceitua o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, sendo necessária, contudo, a existência de "fundada suspeita" de que o indivíduo alvo da busca esteja na posse de arma ou papéis ou objeto que constituam corpo de delito. A questão, portanto, que se tem a examinar é se, no caso, existia ou não fundada suspeita da prática de ilícito penal, de maneira a autorizar a realização da busca pessoal, impondo-se a conclusão afirmativa.

Isso porque, malgrado as fundadas razões ou suspeitas não equivalham ao mero achismo, por natureza dotado de extremado subjetivismo, certo é que sua compreensão pode (e às vezes até deve) ser construída a partir de uma conjugação de fatores. No caso concreto, os policiais militares estavam em patrulhamento visando à repressão ao crime de tráfico de droga, e deram ordem de parada ao caminhão ocupado pelos correus, ação cuja legitimidade parece não se colocar em dúvida, porquanto inserida no âmbito das atribuições legais e constitucionais de referidos profissionais. Ademais, especialmente no que atine à busca pessoal e no caminhão, impõe-se atentar que, diferentemente do quanto sustentado pela D. Defesa, a formação das fundadas suspeitas, como se pode extrair de seus depoimentos policiais, não emergiu pura e simplesmente do suposto nervosismo dos acusados, mas sim da conjugação dessa percepção com a dissonância entre as versões apresentadas por ambos quanto à origem e destino final da viagem. Em outros termos, a busca não se deu, como se alega, apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança, mas pela avaliação conjugada das circunstâncias, especialmente a disparidade dos relatos apresentados pelos corréus, como pontuado.

Diante disso, reputo que, no caso concreto, os elementos extraídos no momento da abordagem eram suficientes para produzir as fundadas suspeitas, que justificadamente conduziram os agentes policiais a prosseguir na averiguação, chegando ao ato de busca pessoal e do veículo. Assim, não vislumbrando nulidade na busca realizada pelos policiais, rejeito a preliminar de nulidade, declarando a validade da prova, cuja potencialidade para demonstrar ou não os crimes será examinada no mérito.

No mérito, ação penal é procedente apenas no que tange ao réu JOSENILO e tão somente no que atine ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se cabalmente demonstradas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), fotografias (fls. 19/22), laudo toxicológico (fls. 148/150), laudo pericial (fls. 159/161), laudo pericial do celular apreendido (fls. 162/171) e pela prova oral colhida durante a instrução.

Os policiais militares Luís Gustavo da Silva Schwarz e Fernando Ferrer afirmaram, em uníssono, que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pela Rodovia Raposo Tavares, quando, próximo ao pedágio de Assis, realizaram a abordagem ao caminhão placa MHP2I95, acoplado com o reboque AFL8I68, conduzido por JOSENILO e, como passageiro, DANIEL. Ao conversar com o motorista, JOSENILO demonstrou nervosismo. Por tal razão, os agentes públicos separaram o motorista (JOSENILO) e o passageiro (DANIEL). Ambos deram versões contraditórias sobre a origem e o destino final. Assim, conduziram o caminhão até o Posto de Combustível Novoeste, Km 453, local em que foi realizada busca minuciosa no caminhão. Entre as logarinas do chassi do cavalo trator, foi localizado um fundo falso em formato de cofre, em cujo interior havia várias munições de calibres restritos, sendo 7.62 e .50, além de cinco tabletes cocaína e 12 de crack. Continuando a vistoria, foram localizadas mais duas caixas de munições .50, as quais estavam escondidas em uma caixa de ferramentas,

sob o reboque. Foi dada voz de prisão a JOSELINO e DANIEL. Ambos alegaram que carregaram o caminhão em Campo Grande/MS e o deixariam em um posto de combustível na entrada de São Paulo, próximo a Régis Bittencourt. Por fim, a testemunha Fernando acrescentou que JOSENILO o contou que receberia R\$ 20.000,00 e pagaria R\$ 2.000,00 a DANIEL.

Em juízo, os policiais apresentaram relato idêntico àquele prestado em fase policial. Acrescentaram que DANIEL negou conhecimento das drogas e munição, e disse que receberia R\$ 2.000,00 para acompanhar JOSENILO. Em relação ao local em que foram encontradas as drogas, informaram que era feito sob uma chapa de ferro e de difícil acesso. E ainda disseram que JOSENILO quem conduzia o caminhão e DANIEL não conseguiria visualizar o dispositivo colocado no caminhão, não sendo original daquele veículo. Foi nesse dispositivo em que encontraram as drogas e as armas, que estava fechada e preciso ferramentas para chegar até a droga.

Interrogado, o acusado JOSENILO confessou apenas o transporte de munições.

Esclareceu que o caminhão e o semi-reboque que conduzia lhe pertence. Estava em Campo Grande, local onde encostou o caminhão em um Posto de Combustível de nome Locatelli, na Rodovia 262. No local, combinou com um rapaz desconhecido para que o réu as munições no destino, desconhecendo que também iria transportar drogas.

Receberia a quantia de R\$ 20.000,00. Passado um tempo, outro rapaz foi ao local, o qual não conhece e nunca viu e pegou o caminhão do interrogando, retornando somente a noite e já carregado. Deixaria as munições em qualquer posto no início da Rodovia Régis Bittencourt; um carro iria interceptá-lo e indicaria o local. Somente receberia quando entregasse a encomenda. Desconhecia que também transportava drogas, pois o combinado eram apenas as munições. Foi abordado por policiais militares em posto de combustível próximo ao pedágio nesta cidade e lá os policiais já foram dizendo que a casa havia caído e que sabiam que o interrogando estava transportando drogas. Após levaram o caminhão para outro posto e localizaram as munições e drogas. Quanto a Daniel, disse que ele foi contratado para descarregar as latinhas, mas não foi preciso, porque a segunda empresa que adquiriu, responsabilizou-se pela descarga e que Daniel não participou em nada, nem do carregamento, nem do descarregamento. E acrescentou que Daniel nunca tinha viajado com ele, e não tinha o celular dele.

Interrogado, o réu DANIEL negou a prática delitiva. Disse que conhece JOSENILO há poucos meses e que ele lhe ofereceu R\$ 2.000,00 para o interrogando acompanhá-lo e ajudá-lo a descarregar o caminhão, que estaria carregado de cervejas. Chegaram em Campo Grande na sexta-feira à noite e dormiu no caminhão. Não sabe por qual motivo o caminhão não foi descarregado no sábado. No domingo, acordou e foi tomar banho no posto. Ao retornar, o caminhão não estava mais lá. Ao indagar JOSENILO, este informou que o caminhão já tinha saído para descarregar. O caminhão retornou vazio e sem a lona. No domingo, seguiram viagem com o caminhão vazio. Foram abordados por policiais rodoviários, os quais já diziam que o caminhão estava com drogas. Os policiais levaram o caminhão até outro posto e lá encontraram bastante munições e drogas.

Pois bem. Diante das provas colhidas em juízo, conclui-se que a ação deve proceder tão somente com relação ao réu JOSENILO e apenas no atine ao crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/03.

Isto porque, no direito penal, afasta-se a responsabilidade objetiva. No caso em hipótese, as provas evidenciam que JOSENILO não tinha ciência da existência das drogas. Conforme ele próprio confessou, o transporte contratado envolvia tão somente as munições. Ademais, os policiais também asseveraram que os entorpecentes foram encontrados em local de difícil acesso (sob uma chapa de ferro), sendo necessário o uso de ferramentas.

Deste cenário, extrai-se que tampouco houve dolo eventual por parte de JOSENILO no que tange às drogas. As mensagens e áudios de WhatsApp transcritos a fls. 162/171 demonstram que as tratativas versavam sobre armamentos, sem referências a transporte de entorpecentes. O fato de ter deixado o caminhão para carregar não necessariamente implica dizer que o réu tinha conhecimento sobre a droga, uma vez que a quantia de munições se revela vultosa e também demandaria um tempo para carregar. Portanto, não ficou provado, com a certeza necessária, própria da

cognição exauriente, o dolo de JOSENILO sobre a existência do entorpecente, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição neste particular.

Já no que tange ao crime de transporte de munições, previsto no art. 16, da Lei 10.826/03, de rigor a procedência da ação penal, conforme se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), fotografias (fls. 19/22), laudo pericial (fls. 159/161) e da prova oral colhida em juízo. Essa é a conclusão que emerge do acervo probatório, inclusive corroborado pela confissão do réu JOSENILO.

Ademais, a eficácia das munições está provada pericialmente (fls. 159/161).

Já com relação ao corréu DANIEL, emergem dúvidas acerca de sua participação nos delitos descritos na inicial acusatória.

Isso porque, os policiais militares afirmaram que DANIEL acompanhava JOSENILO, e ele teria dito que fora contratado por aquele para descarregar, recebendo o valor de R\$ 2.000,00, equivalente a dez diárias. Nesse sentido, o acusado JOSENILO, em interrogatório, afirmou que DANIEL não participou do carregamento nem do descarregamento, e não sabia da ilicitude dos objetos.

Assim, não havendo qualquer outro elemento que indique o acusado Daniel tinha ciência do transporte das drogas e das munições, sua absolvição é a medida que se impõe.

Por fim, não prospera o tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006, porque não há provas de que os acusados se uniram de maneira estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo elementos para se concluir que a situação se apartara de mero concurso de agentes, pseudo-concurso, insuscetível de configuração de crime autônomo. Não basta que duas pessoas pratiquem juntas o tráfico de drogas para incidirem em tipo autônomo, na medida em que o núcleo do tipo é associarem-se, que denota, por sua semântica, os elementos da estabilidade e permanência, imprescindíveis à tipicidade formal. Portanto, apenas o ajuste entre dois ou mais indivíduos que se estabiliza é que permite a incidência do art. 35, ainda que as tratativas duradoras sejam para a prática de um único crime de tráfico de drogas; motivo pelo qual a lei vale-se da expressão "reiteradamente ou não". Nesta direção, e.g, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. II De outro lado, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/06 (REsp. 1.113.728/SC, Min. Rel. Felix Fischer, 5ª T., j. 29.09.2009) (destaquei).

Destarte, impõe-se o desacolhimento da pretensão, nesse particular.

Portanto, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao art. 16, da Lei 10.826/03) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena:

RÉU JOSENILO:

Crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/03:

Na primeira fase, verifica-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, em razão da grande quantidade de munições apreendidas, pelo que elevo a pena-base em 1/3. Ainda, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta em virtude de que o transporte das munições envolveu dois Estados da Federação (MS e SP), pelo que elevo a pena em 1/5 e a fixo em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, além de 15 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Presente, porém, a atenuante da confissão, o que enseja a diminuição de 1/4, totalizando 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, de forma que a pena, no que tange ao crime de transporte de munições, perfaz 3 anos, 7 meses

e 6 dias de reclusão, além de 11 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

a) CONDENAR o réu e JOSENILO FERREIRA ao cumprimento de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao art. 16, da Lei 10.826/03;

b) ABSOLVER os réus JOSENILO FERREIRA e DANIEL SANTOS DE JESUS das imputações referentes aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, respectivamente, do CPP;

c) ABSOLVER o réu DANIEL SANTOS DE JESUS da imputação referente ao crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/03, com base no art. 386, inc. V, do CPP.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, tendo em vista reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias (grande quantidade de munições apreendida) indica que a substituição não é suficiente e recomendável.

Suspensão condicional da pena: incabível, diante da pena imposta ser superior a dois anos (art. 77, do CP).

Prisão preventiva: não se encontram presentes os requisitos legais.

No que tange aos bens apreendidos, determino o perdimento de todos, inclusive do veículo utilizado para o transporte das drogas. Oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado:

(1) suspendam-se os direitos políticos do sentenciado JOSENILO, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente; e

(2) intime-se o réu JOSENILO ao pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias, sob a pena de inscrição de seu nome em cadastro de dívida ativa.

Por fim, dispenso o réu JOSENILO do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA